

1500201-60.2022.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala.

Além do relato seguro dos guardas civis no sentido de que apreenderam as porções de 'crack' em poder do acusado, o próprio increpado afirmou que estava na posse das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500201-60.2022.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500201-60.2022.8.26.0546

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX RAFAEL DE ALMEIDA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Alex Rafael de Almeida foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 02 de abril de 2022, por volta das 13h30min, na Rua José Franco de Carvalho, nº 270, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, juntamente com um adolescente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 26 (vinte e seis) embalagens, contendo 10 gramas da droga crack (derivada da cocaína), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e alterações posteriores). O acusado foi notificado (fls. 158), apresentou defesa prévia (fls. 147/148) e a denúncia foi recebida aos 06 de julho de 2022 (fls. 149/150).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em memoriais, o representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal e condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, III da lei antidrogas.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20 e 22); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 21 e 23/24); pelo laudo pericial do local (fls. 98/102); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 133/135) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Henrique da Silva disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, avistou o acusado, que estava sentado em um banco, submeteu-o a busca e localizou 26 porções de crack nas mãos dele. O acusado disse que estava passando dificuldade financeira. Disse que havia outro indivíduo pelas imediações, que estava a cinco metros de distância do acusado, e agachado era adolescente e nada foi encontrado com ele, mas, no local onde ele estava mexendo, localizou 35 eppendorfs de cocaína (fls. 02).

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo guarda municipal Fabio dos Santos Codogno, que avistou o acusado em um banco. Submeteu-o a busca e localizou 26 porções de 'crack' em sua cintura. Havia outro indivíduo próximo ao acusado, mas não os viu conversando.

Em solo policial, o acusado Alex Rafael de Almeida disse que está desempregado e aceitou pegar um "kit" de crack e deveria entregá-lo a uma pessoa que não sabe qualificar. Disse que fez isso por estar passando por necessidade financeira. Disse que o kit de crack estava em seu poder no momento da abordagem. Quanto ao outro rapaz, que o conhece de vista, mas que nada viu sobre a abordagem sofrida por ele (fls. 09).

Em juízo, o acusado disse que não estava em companhia do adolescente, que não estava em companhia do interrogando. Confirma que a droga apreendida estava em sua mão porque enfrentava dificuldade financeira. Afirma que indivíduo lhe ofereceu R\$ 500,00 para que fizesse duas entregas de drogas a terceira pessoa.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala.

Além do relato seguro dos guardas civis no sentido de que apreenderam as porções de 'crack' em poder do acusado, o próprio increpado afirmou que estava na posse das porções e as transportava porque enfrentava dificuldade financeira.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

"Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

E nem se alegue dificuldade financeira como excludente para a prática do crime de tráfico de drogas, pois a doutrina leciona que: não é motivo para a prática de

tráfico ilícito de entorpecentes, pois os bens jurídicos são desproporcionais. Aquele que alega estar em dificuldade financeira para cometer os delitos previstos nos artigos 33 e 34 desta lei termina por colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade. Logo, em face da desproporcionalidade entre os bens jurídicos em jogo, não se pode acolher essa tese. Por outro lado, a situação de pobreza também não é justificativa para o cometimento de crimes (Guilherme de Souza Nucci. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Pág. 365. Ed. Revista dos Tribunais. 5ª edição).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais, na medida em que o próprio acusado disse que não os conhecia e nada tinha nada contra eles, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade em seu patamar mínimo, pois favoráveis as circunstâncias judiciais, de modo que fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo sobre a pena aplicada, pois já estipulada no mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, Lei n. 11.343/06 já que o laudo pericial do local revela que nas imediações estão localizados estabelecimentos de ensino e praças públicas o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas.

Aliás, a lei não exige que o estabelecimento de ensino seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Quanto à alegação de que o entorpecente não seria comercializado no local, consigno que não há prova nesse sentido, apenas a alegação do acusado, de modo que a tese não pode ser acolhida.

Ainda em terceira fase, deve ser afastada a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, VI, da lei n. 11.343/06, pois não há prova de que o acusado envolveu adolescente em sua prática delitiva, já que os guardas civis afirmaram que o

inimputável estava a cinco metros de distância e não manteve contato com o increpado.

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois o acusado ostenta condenação criminal nos autos n. 0005540-41, da 2ª Vara da Comarca de Amparo, que, apesar de não contar com trânsito em julgado, demonstra seu envolvimento em atividades criminosas.

Em hipótese semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: Embora não se tenha notícia de trânsito em julgado, já foi condenado em outro processo por crime da mesma estirpe, circunstância que, aliada à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, delineia ter a narcotraficância como meio de subsistência. E como a 'mens legis' da redutora foi a de beneficiar o agente que tivesse imerso no submundo do crime em situação de mero desvio de conduta, caracterizando o "marinheiro de primeira viagem", como mencionado pela doutrina, não há como conceder a benesse legal na hipótese. O cenário projetado, portanto, revela fatores sintomáticos da dedicação contumaz do réu ao tráfico de drogas, o que fundamenta o afastamento da benesse legal conferida em primeira instância, reconduzindo a pena ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso (TJSP, Apelação n. 0002956-24.2010.8.26.0362, 4ª Câmara de Direito Criminal Extraordinária, Relator designado Des. Euvaldo Chaib, julgado aos 7/8/2014).

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pois não supera o patamar de oito anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO Alex Rafael de Almeida à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime de tráfico de droga atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento dessa prática espúria. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime. Expeça-se certidão de honorários ao patrono dativo nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 26 de agosto de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA